

1500195-41.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... conta de que o estaria ocorrendo tráfico de drogas no Bairro dos Servidores, policiais civis diligenciaram até o local e realizaram campana, com veículo descaracterizado. Assim, observaram que, pelo local dos fatos, MARCOS e o irmão adolescente, realizavam abertamente o tráfico em via pública, constatando-se que 04 (quatro) usuários, não identificados, foram a pé, um de cada ...

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Processo nº 1500195-41.2022.8.26.0453 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-41.2022.8.26.0453

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087935/2022 - DEL.POL.PIRAJUI, 2087935/2022 - DEL.POL.PIRAJUI, AV3430-1/2022 - DEL.POL.PIRAJUI, 2087935 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Antônio Galo

Réu Preso

MM Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu presentante oficiante nesta comarca, em face de Marcos Antônio Galo, dando-o como incurso no art artigo 33, caput, c. c. o art. 40, inciso VI, e no artigo 35, caput c.c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343 de 2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Segundo consta da acusação, no dia 30 de março de 2022, por volta das 17h48min, nesta urbe e Comarca, na esquina da Rua Belmiro da Silva com a Estrada Municipal PRI-010, o acusado: (a) mediante prévio ajuste e agindo em concurso e unidade de desígnios com seu irmão menor Vinicius Felipe Galo, tinham sob sua posse, para fins de disseminação a terceiros, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que foi localizado pelos policiais que realizavam a campana e a abordagem posteriormente, 1 um cigarro de Cannabis Sativa L - maconha (peso líquido de 0,93g) e 2 pedras fracionadas e embaladas para venda de cocaína na forma de crack (peso líquido de 0,35g), e; (b)

em data incerta, mas antes da ocorrência supracitada, nesta urbe e comarca, teria se associado com seu irmão, o adolescente Vinicius Felipe Galo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. Assim o D. Promotor narrou as circunstâncias do crime:

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado MARCO ANTÔNIO, agindo em conjunto com o adolescente Vinicius, associaram-se, de maneira estável e permanente, exercendo divisão de tarefas, para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com efeito, após delações anônimas, dando conta de que o estaria ocorrendo tráfico de drogas no Bairro dos Servidores, policiais civis diligenciaram até o local e realizaram campana, com veículo descaracterizado. Assim, observaram que, pelo local dos fatos, MARCOS e o irmão adolescente, realizavam abertamente o tráfico em via pública, constatando-se que 04 (quatro) usuários, não identificados, foram a pé, um de cada vez, até eles, pegavam a droga com Vinicius, davam o dinheiro ao maior MARCOS e depois saíam rapidamente, movimento este característico do tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos, quando um quinto usuário se aproximou, os policiais civis realizaram abordagem, sendo que, em buscas pessoais, encontraram no bolso do adolescente Vinicius, 01 cigarro de substância popularmente conhecida como maconha e 02 (duas) pedras de crack, já embaladas individualmente e prontas para a venda, juntamente com um aparelho celular, marca Samsung, pertencente à Fábio Willian Florino, em cuja capa plástica havia R\$54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro. Por sua vez, em poder de MARCOS foi encontrado R\$100,00 (cem reais), em notas diversas.

Interrogado, o denunciado negou a prática delitiva (fl. 10).

Assim, o tráfico desponta comprovado, diante das circunstâncias da prisão de MARCO ANTÔNIO, realizada após o recebimento de delações anônimas dando conta da prática da mercancia ilícita de drogas comprovada por campana realizada por policiais civis, pela apreensão de dinheiro proveniente da traficância, fracionado em notas diversas, pelas declarações colhidas nos autos, bem como pelo fato de o denunciado já ser conhecido nos meios policiais pela prática do mesmo delito. (fls. 44/55, 85/91 e 93/94).

Da mesma forma a associação para o tráfico de drogas entre eles desponta comprovada pelas circunstâncias da detenção do denunciado e seu irmão, também conhecido por praticar a traficância (fls. , o que corrobora que o investigado, juntamente com o adolescente Vinicius (fls. 72/74), praticavam o comércio ilícito de entorpecentes, de forma habitual e permanente.

Autuado em flagrante delito (fls. 1), este juízo, em audiência de custódia, deliberou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 95/100).

O denunciado foi regularmente notificado (fls. 157/158).

Defesa prévia apresentada pelo seu D. Defensor (fls. 164/168). Aduz que a apreensão de um grama de crack e um cigarro de maconha não são suficientes para embasar uma denúncia ou um decreto condenatório em tráfico de entorpecentes. Requereu a liberdade provisória do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para uso pessoal.

Por decisão datada de 20/05/2022, foi recebida a denúncia e determinada a produção de prova oral (fls. 176/177).

Em solenidade foram ouvidas duas testemunhas de acusação, um informante de defesa e interrogado o acusado (fls. 234/235).

As partes apresentaram alegações finais escritas, sendo que o D. Promotor pugnou pela parcial procedência da inicial (fls. 245/256) e o D. Defensor, além de requerer a liberdade provisória do acusado (fls. 258/261), pleiteou a absolvição do réu (fls. 265/270).

Sendo este o introito, decido.

Adianto que a pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19 e 20/21), auto de reconhecimento (fls. 28), laudos de constatação provisória (fls. 22/27) e definitivo (fls. 121/125), relatório final (fls. 129/134), laudo do

celular apreendido (fls. 212/217 e 218) e respectivo relatório policial (fls. 220/226).

A autoria também é certa, no que tange ao delito de tráfico.

EVANDRO APARECIDO MESQUITA, policial civil e testemunha comum, disse na fase policial o seguinte (fl. 4/5): "Que é Policial Civil nesta Delegacia de Polícia de Pirajuí e nesta data recebeu denúncia anônima de que no final da tarde, durante a troca de plantão da Polícia Militar, em razão da diminuição do policiamento, estaria ocorrendo tráfico de drogas nas vias públicas do bairro Jardim dos Servidores, nesta cidade; Que diante de tal denúncia, diligenciou juntamente com o investigador Paulo Renato até aquele bairro com viatura descaracterizada e passaram realizar campana, observando à distância a movimentação ali existente, oportunidade em que puderam constatar que na esquina da Estrada Municipal PRI-010 com a Rua Belmiro da Silva, no bairro Jardim dos Servidores, o maior Marcos Antônio Galo e seu irmão, o adolescente Vinícius Felipe Galo, vulgo "Galinho", de 17 anos de idade, ambos já conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, realizavam abertamente, em via pública, a venda de entorpecentes; Que durante o período em que observaram, constataram que 04 (quatro) usuários não identificados foram a pé, um de cada vez, até os investigados, trocaram algo e saíram andando rapidamente, realizando procedimento suspeito, característico de locais onde ocorre a venda de drogas ilícitas, sendo possível identificar ainda que referidos usuários pegavam a droga com o adolescente Vinícius e davam o dinheiro ao maior Marcos; Que quando um quinto usuário aproximou-se de bicicleta dos irmãos, resolvemos realizar a abordagem, ocasião em que foi realizada busca pessoal, durante a qual foram encontrados em poder do adolescente Vinicius, em seu bolso, 01 (um) cigarro de maconha e 02 (duas) pedras de crack, embalados individualmente em invólucros plásticos e prontos para venda, juntamente com um aparelho de telefone celular da marca Samsung, em cuja capa plástica de proteção havia R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro; Que já em poder do maior Marcos, durante revista, foi encontrada a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em notas variadas, que estava em seu bolso. Que não foi possível abordar o quinto usuário, que conseguiu evadir-se de bicicleta, sem ser identificado; Que ainda no local, o depoente e seu colega receberam denúncia anônima de que o aparelho de telefone celular encontrado em poder do adolescente Vinícius pertencia a Fabio Willian Florino, vulgo "Jhonny Língua", pessoa já conhecida nos meios policiais por ser usuário de substâncias entorpecentes; Que diligenciaram ao encontro de Fabio, sendo o mesmo localizado na via pública, nas proximidades de sua residência no bairro Vila Ortiz, nesta cidade, ocasião em que, ao ser abordado, o mesmo entregou ao depoente e a Paulo Renato 01 (uma) pedra de crack que ele trazia consigo para seu consumo próprio. Que ao ser questionado, Fabio confirmou que ele e seu irmão Vagner Roberto Florino Júnior são usuários de crack, afirmando que ainda costumam comprar drogas do adolescente Vinícius Felipe Galo, tendo Fabio esclarecido que seu aparelho de telefone celular foi recentemente dado por seu irmão Vagner ao adolescente Vinícius, como pagamento por dívida de drogas; Que, diante dos fatos, o maior imputável Marcos Antônio Galo recebeu voz de prisão e o adolescente Vinícius Felipe Galo voz de apreensão, sendo ambos conduzidos até esta unidade policial para as providências de polícia judiciária cabíveis". Em juízo, EVANDRO corroborou com o anteriormente alegado. Disse que recebia denúncias que no local, que só possui um acesso. Quando a viatura chegava, conseguiam se evadir. Os policiais ficaram de campana. Viram 4 pessoas chegando. Quando veio um 5º, decidiram abordar. O dinheiro era pago a Vinicius, que passava para o Marcos. Com o Marcos tinha 100 em notas fracionadas. Os irmãos são conhecidos no meio policial. Na ocasião, eles estavam sentados lado a lado. Os usuários entregavam o dinheiro ao menor, que passava a droga, e depois passava o dinheiro ao Marcos. Uma semana antes, passou no local, mas estava sozinho. Mas não efetuou a abordagem, pois estava sozinho. Eles estavam manipulando a droga. A pedra custa 10 reais.

FABIO WILLIAN FLORINO, testemunha comum, declarou na fase policial (fl. 8) o seguinte: "Que o depoente é usuário de drogas; Que há cerca de um mês adquiriu um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A02, de cor azul, pelo valor de R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais); Que há duas semanas seu celular sumiu

de sua casa, depois de ter emprestado ele a seu irmão Vagner Roberto Florino Júnior, o qual também é usuário de drogas; Que após ir perguntando a várias pessoas, o depoente descobriu que seu irmão havia dado seu celular como pagamento de uma dívida de drogas ao adolescente Vinícius "Galinho", uma vez que populares lhe contaram que viram Vagner conversando com Vinícius no "Inferninho", nome pelo qual é popularmente conhecido o bairro Jardim Eldorado; Que o depoente questionou "Galinho" sobre seu celular, sendo que o mesmo alegou que o celular não mais estava com ele, mas que já havia estado; Que por diversas vezes o depoente comprou drogas de Vinícius Galo, conhecido como "Galinho"; Que geralmente compra no peso, para sair mais barato, sendo que paga R\$ 170,00 (sento e setenta reais) por 05 (cinco) gramas de crack; Que às vezes o depoente chega a consumir as 05 (cinco) gramas de crack em uma noite, junto com seu irmão Vagner; Que nesta tarde foi abordado por Policias Civis, oportunidade em que foi indagado se estava com algo irregular, sendo que de imediato disse que estava com uma pedra de crack no bolso para seu consumo pessoal, a qual foi entregue aos policias; Que os policias perguntaram sobre o seu telefone celular, momento em que lhes informou que tal aparelho estava na posse de Vinícius Galo; Que o depoente foi trazido até esta Unidade Policial, onde reconheceu o celular apreendido em poder do adolescente Vinícius como sendo de sua propriedade". Em juízo, FABIO corroborou com o anteriormente alegado. Disse que deixou seu celular com seu irmão Vagner. Seu irmão é usuário. Soube que o celular estava com o "galinho" - Vinícius. Já comprou drogas de Vinícius, irmão do réu. Reconheceu seu celular na delegacia. No dia, ia comprar deles.

VINICIUS FELIPE GALO, testemunha da defesa foi ouvido em juízo como informante por ser irmão do acusado. Em solo policial, disse o seguinte: "[...] Que, quanto aos fatos, informa que hoje por volta das 17h30min estava juntamente com seu irmão Marcos Antônio Galo na esquina da Rua Belmiro da Silva com a estrada PRI-010, no jardim dos Servidores. Que Policias Civis chegaram de repente e os abordaram, ocasião em que localizaram em seu bolso duas pedras cracks e um cigarro de maconha, um aparelho celular Samsung A02 azul e uma quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais); Que com seu irmão encontraram a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Que o declarante nega envolvimento com o tráfico de drogas e alega que as duas pedras crack e o cigarro de maconha eram para seu consumo pessoal, a quantia de R\$ 54,00 (cinquenta reais) foi um dinheiro que sobrou de uma troca que fez, ou seja, o declarante deu um aparelho celular e uma bicicleta para uma pessoa, que não sabe informar o nome nem endereço, e esta pessoa lhe devolveu o aparelho celular que estava na sua posse e mais o valor de R\$ 100,00 (cem reais); Que já havia gastado quase metade do dinheiro; Que hoje quando foi abordado pelos Policias Civis não estava vendendo drogas, estava apenas sentado na esquina do bairro com meu irmão Marcos. Que já vendeu drogas há uns dois anos atrás, porém, alega que não vende mais; Que seu irmão saiu da prisão há cerca de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que ele ficou preso por cerca de 5 (cinco) meses pela pratica de tráfico de drogas". Em juízo, e ouvido como informante, VINICIUS alegou que, no dia dos fatos estavam perto da rua em que moravam, sendo que a droga apreendida era sua.

MARCOS ANTONIO GALO, acusado, em solo policial, disse o seguinte (fl. 10): "Que no momento que os Policiais chegaram estava na esquina da Rua Belmiro da Silva com a Estrada PRI-010, com seu irmão Vinicius Felipe Galo, onde havia acabado de chegar ao local e estava fumando um cigarro; Que consigo não foi encontrado qualquer entorpecente e o valor de R\$100,00 (cem reais) que foi encontrado era referente a um bico que realizou de servente de pedreiro há 3 (três) semanas, quando recebeu no total R\$800,00 (oitocentos reais); Que se encontrava preso por tráfico de drogas e teve sua liberdade concedida há 45 dias; Que hoje usa maconha mas não vende, que já vendeu entorpecentes mas hoje não mais pratica o comércio de drogas; Que não sabia que seu irmão Vinicius Felipe Galo estava vendendo entorpecentes". Interrogado em juízo, disse que não se associou com seu irmão para vender drogas e que não estava traficando. No dia do fato estava em sua casa quando acabou seu cigarro e foi ao bar comprar, próximo à esquina que seu irmão estava e ficou conversando com ele. Chegou lá não fazia cinco minutos. Lá estavam seu irmão e outro adolescente. Viu uma caminhonete se aproximando rápido, sendo que, quando ela parou, viu que eram os policiais civis. Foram abordados e acharam a droga com seu irmão, mas não sabia que

ele tinha droga e que ele estaria vendendo drogas ali. Seu irmão teria dito aos policiais, no momento da abordagem, que a droga era para seu uso. Sabia que seu irmão praticava o tráfico. Confirmou que praticou o tráfico, mas no momento não estava traficando. O dinheiro encontrado com ele veio do trabalho de servente, sendo que ganhava trinta reais por dia, e era o dinheiro que tinha sobrado. Não soube dizer o porquê da alegação dos policiais. Disse que não viu nenhum usuário no local, apenas o adolescente. Conhecia o Policial Evandro. Não conhecia Fábio. Pois bem.

Da análise do manancial probatório contido nos autos, tem-se que a procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Com efeito, os depoimentos harmônicos e coerentes do policial, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são uníssonos a apontar a autoria do delito por parte do acusado, que foi localizado e visualizado pelos policiais, que estavam em campanha, na prática da mercancia ilícita juntamente com seu irmão menor, na guarda do dinheiro.

Nesse ponto, cumpre destacar que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 - SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ: "A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que o policial fosse acusar falsamente o réu. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, prestados tanto em juízo quanto na fase policial, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado ao grande número de ocorrências atendidas pelos policiais. Por outro lado, a versão defensiva apresentada pelo acusado restou isolada e inverossímil.

A uma, porque os policiais foram enfáticos ao afirmar que encontraram o réu e o menor infrator, praticando a mercancia ilícita com divisão de tarefas de entrega de entorpecentes e recepção do dinheiro.

A duas, porque inexistente qualquer indício nos autos que pudesse levantar dúvida quanto à credibilidade da palavra dos policiais, os quais não possuíam motivos para incriminar falsamente o réu.

A três, porquanto o acusado já responde a outro processo criminal também pelo crime

de tráfico de drogas (fls. 88 - Autos nº 1500195-41.2022.8.26.0453), e dispõe de antecedentes infracionais pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime (fls. 93/94), o que condiz com a tese acusatória da prática de mercancia ilícita, e não de mero crime de consumo pessoal de entorpecentes. Em que pese a ínfima quantidade de droga apreendida, as circunstâncias permitem concluir que o acusado, juntamente com seu irmão menor, estava traficando substâncias entorpecentes. Assim, longe de ser precária, a prova dos autos é uniforme em incriminar o réu, encontrando amplo amparo nas palavras das testemunhas ouvidas.

Cumprе enfatizar, outrossim, que o fato de o réu alegar ser usuário de substância entorpecente não o exonera da responsabilidade pela prática do delito descrito na denúncia, sobretudo porque a realização da mercancia ilícita poderia se dar exatamente para garantir o próprio uso ou vício.

Não se olvide, outrossim, que a condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo.

A propósito, o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

Em outras palavras, o crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Nesse diapasão, já se decidiu que “a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo” (STJ, Rec. Esp. nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

No mais, acerca da alegada insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, é possível acrescentar a jurisprudência do STJ: “Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.

Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).

Logo, a variedade de drogas, ainda que encontradas em quantidade ínfima, aliado as circunstâncias em que foi surpreendido o réu, e seus antecedentes infracionais pelo mesmo ilícito, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido, em notas fracionadas, típicas da traficância, o que afasta a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Sendo assim, de rigor a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não merecendo acolhida a tese absolutória e desclassificatória.

Por outro lado, quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/06, tenho que a pretensão acusatória não procede, porquanto não comprovado nos autos que os acusados estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, de forma estável e permanente ainda que em período curto. Apenas o tráfico em concurso de pessoas restou comprovado, o que não autoriza o decreto condenatório para este tipo penal. Nenhuma prova nesse sentido foi carreada.

Com efeito, não houve investigação aprofundada que demonstrasse que havia divisão de tarefas entre os denunciados. Houve apenas a prisão em flagrante delito de tráfico de drogas e tal circunstância não comprova, com segurança, a estabilidade e permanência da associação para o tráfico encetada pelos acusados, ensejando o não reconhecimento de tal delito.

Nesse sentido, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “PENAL.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n.7/STJ.

1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se enquadra ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, de que não restou demonstrada a existência de vínculo associativo entre os réus, de forma estável e permanente, visando o comércio ilegal de drogas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 630.917/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06/12/2016).

Urge ressaltar que, a despeito da gravidade do fato imputados ao acusado, isso não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário de se condenar um inocente, considerando a fragilidade do conjunto probatório.

De rigor, assim, a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", a ensejar a absolvição do acusado pelo crime do art. 35, "caput", da Lei 11.343/2006.

Autoria e materialidade comprovadas, passo à dosimetria das penas, atento ao sistema trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, segundo os critérios do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade encontrada com o acusado é ínfima, motivo pelo qual não merece incremento. Quanto às demais circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, é normal ao caso. O acusado não possui maus antecedentes, consoante se verifica nas certidões de fls. 52/54, nos termos da Súmula 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), salientando-se ainda que atos infracionais pretéritos não podem ser considerados para fins de antecedentes criminais (STJ. 5ª Turma. HC 499987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 30/05/2019). Ademais, inexistem elementos para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do sentenciado. O motivo da conduta não é especialmente censurável. As circunstâncias foram inerentes ao delito, já tendo sido sopesadas pelo legislador. As consequências não extrapolaram o comum à espécie. Por se tratar de crime vago, não há se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena base no piso em 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na etapa intermediária, verifico a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), pelo fato de o réu ter cometido o delito com menos de 21 anos. Entretanto, a pena já se encontra no mínimo, sendo inviável a aplicação das minorantes (Súmula 231, STJ), de forma que a pena intermediária mantém-se em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que presente a causa de aumento presente no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi cometido em concurso com menor de idade. Aumento a pena em 1/6: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Entendo incabível a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, ao instituir a referida causa de diminuição da pena, o legislador objetivou beneficiar o agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, e cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida seria suficiente para a ressocialização e reprovação do comportamento. No caso em tela, contudo, verifico que o acusado possui mais de um antecedente infracional (fls. 93/94), estando atualmente respondendo a outro processo criminal pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (Autos nº 1501262-74.2020.8.26.0594 - fl. 88), tudo a indicar sua dedicação a atividades criminosas, a inviabilizar a referida benesse.

E, sobre a possibilidade de se utilizar o histórico de ato infracional para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, colaciona-se o seguinte precedente do C. STF: "Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria.

Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021).

Desse modo, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa..

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Considerando a quantia de pena aplicada, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da reprimenda (art. 77 do CP), diante do patamar da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia para:

a) CONDENAR o réu MARCOS ANTONIO GALO, já qualificado, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecido este no mínimo legal;

b) ABSOLVER o réu MARCOS ANTONIO GALO, já qualificado, do delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, por fragilidade probatória, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Por se tratar de crime vago, é descabida a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O acusado respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação, especialmente em virtude da gravidade concreta do delito e do fato do réu já estar respondendo criminalmente pela prática do mesmo crime, o que afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, pois insuficientes outras medidas diversas da segregação cautelar. Portanto, deixo de lhe facultar o recurso em liberdade, devendo-se observar, entretanto, o regime semiaberto que ora foi imposto ao condenado, para fins de segregação enquanto não julgado eventual recurso defensivo.

Autorizo a destruição da droga apreendida. Oficie-se, servindo esta sentença, com cópia do auto de apreensão, como ofício.

Custas pelo condenado (100 UFESPs), ressalvada a gratuidade concedida.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à cobrança;

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento;

c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido às fls. 18/19 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União;

d) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao patrono nomeado para o réu conforme o valor da tabela do convênio DPE/OAB. Após a certificação do trânsito em julgado, expeça a z. Serventia Judicial a respectiva certidão.

P.I.C.

Pirajuí, 11 de julho de 2022.

RAFAEL MORITA KAYO, Juiz de Direito

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita